

1500060-40.2022.8.26.0611

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PUGLIESI LEITE

Comarca: Guará

Foro: Foro de Guará

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta, ainda, que no dia 13 de abril de 2022, aproximadamente às 15h45min, na Estrada Vicinal José Landim, na altura do km nº 7, nesta cidade e comarca de Guará/SP, os denunciados transportavam, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 478,58g (quatrocentos e setenta e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guará

Foro de Guará

1ª Vara

Rua Carlos de Campos, 260, Guara-SP - cep 14580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500060-40.2022.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500060-40.2022.8.26.0611

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102726/2022 - DEL.POL.GUARÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO CARLOS AMARO DIAS JÚNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. ADRIANO PUGLIESI LEITE

Vistos.

ROBERTO CARLOS AMARO DIAS JÚNIOR, RAMON DA SILVA DIAS e PAULO ROBERTO HONÓRIO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, em data anterior a 13 de abril de 2022, em horário e local incertos, os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta, ainda, que no dia 13 de abril de 2022, aproximadamente às 15h45min, na Estrada Vicinal José Landim, na altura do km nº 7, nesta cidade e comarca de Guará/SP, os denunciados transportavam, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 478,58g (quatrocentos e setenta e oito gramas e cinquenta e oito centigramas), de maconha, droga esta causadora de dependência física e psíquica.

A inicial narra que Roberto e Ramon, que são irmãos, uniram-se a Paulo e passaram a se utilizar do veículo VW/Golf, placas FIZ4800, para fazer o transporte de drogas

até este município, passando por Ribeirão Corrente/SP, ocasião em que passaram a ser vistos em atitudes suspeitas rotineiramente. Na data mencionada, Roberto, Ramon e Paulo decidiram transportar drogas até este município. Para tanto, Ramon conduziria o veículo, que estava registrado em seu nome e os demais iriam como ocupantes do veículo. Após adquirirem quase meio quilo de maconha, tomaram rumo a Guará, passando por Ribeirão Corrente. Ocorre que a Polícia Militar foi informada e iniciaram o acompanhamento do veículo. Contudo, ao notarem que estavam sendo perseguidos, decidiram se desfazer das drogas e Roberto, que ocupava o banco de passageiro ao lado do condutor, arremessou o tijolo de maconha pela janela. Ato contínuo, os policiais continuaram na perseguição dos denunciados e ao chegar em Guará, Ramon conduziu o veículo até uma estrada de terra, estacionou e todos tentaram empreender fuga. Porém, Roberto e Paulo foram detidos e Ramon conseguiu empreender fuga. Ao retornar ao local que Roberto jogou a porção de drogas, localizaram duas porções de maconha que foram devidamente apreendidas.

Os réus Paulo e Roberto foram citados aos 3 de junho de 2022 (fls. 234 e 236) e apresentaram defesa às fls. 283/286. A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2022, determinando-se o desmembramento dos autos com relação ao acusado Ramon, foragido (fls. 289/290). Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas e interrogados os acusados (fl. 362).

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou a parcial procedência da pretensão punitiva, por entender comprovadas materialidade e autoria apenas em relação ao delito de tráfico de drogas, porque com relação ao delito de associação para o tráfico não foi possível comprovar a estabilidade e permanência entre os acusados (fls. 442/457).

A defesa de Roberto Carlos requereu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal. No mérito, pleiteou sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória (fls. 467/484).

Por sua vez, a defesa de Paulo Roberto requereu sua absolvição do acusado, ao argumento de insuficiência probatória (fls. 498/507).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Por primeiro, registro que a preliminar arguida pela defesa do réu Roberto não merece prosperar, pois não há que se falar em nulidade da busca pessoal:

"Como se sabe, a busca pessoal implica restrição à garantia constitucional da intimidade (art. 5º, inciso X, CF), podendo recair sobre o investigado, acusado, vítima ou terceiro, abarcando suas vestes ou outros objetos ou coisas que estejam em contato com seu corpo. De forma excepcional, a busca pessoal poderá ser realizada sem ordem judicial, nas hipóteses previstas no art. 244, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) no caso de prisão; b) quando houver "fundada suspeita" de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito ou c) no curso de medida de busca domiciliar. De tal dispositivo, portanto, depreende-se que o procedimento de revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos. Aqui, no conflito emergente entre a intimidade e o resguardo imediato da ordem pública, o legislador inclinou-se em favor do último. Nesse sentido, é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito,

ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Hipótese em que o Tribunal de origem, diante das circunstâncias peculiares do caso - veículo parado em atitude suspeita, durante a madrugada, com quatro indivíduos em seu interior - entendeu haver fundada suspeita para a realização da abordagem pessoal, que resultou na apreensão de arma de fogo. A decisão vergastada está em consonância com o art. 244 do CPP e os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido são legítimos para fins de busca pessoal. Rever a conclusão do aresto necessitaria do reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.403.409/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 04/04/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE AUTORIZADA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADAS. (...) III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada (...) (STJ, AgRg no HC 684062/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 03/11/2021)." (TJSP; Apelação Criminal 1502865-19.2021.8.26.0540; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/10/2022; Data de Registro: 09/10/2022).

Verifica-se, portanto, que o procedimento de revista pessoal do acusado deu-se em razão de sua ação suspeita que ao perceber a aproximação dos policiais e o acompanhamento do veículo, empreendeu fuga, dando início à perseguição dos acusados. Estavam, portanto, reunidos os elementos que conferiam justa causa para a busca pessoal. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, NUMERAÇÃO RASPADA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ABORDAGEM POLICIAL. PODER DE POLÍCIA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. RÉU QUE PERMANECEU CALADO NA FASE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. ADVERTÊNCIA CONTIDA NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Se o Tribunal de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos,

entendeu, de forma fundamentada, ser "legítima" a abordagem policial questionada, tendo em vista o local e o horário em que o paciente foi abordado, não cabe a Esta Corte análise acerca da alegada ausência de "fundada suspeita", na medida em que demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. (...) 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC nº 385.110/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J: 06/06/2017, DJe: 18/06/2017).

Não houve, dessa forma, violação da garantia constitucional da intimidade decorrente de busca pessoal ilegal.

No mérito, a pretensão punitiva deduzida na denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 1/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, boletim de ocorrência de fls. 60/63 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 252/254.

A autoria é certa.

O acusado Roberto Carlos Amaro Dias Júnior, ao ser interrogado, disse que tem 28 anos. É casado. Tem três filhos menores que moram com ele. Trabalha na roça com o avô. Respondeu pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Estava vindo de Franca porque foi ver peças para comprar para seu carro. A PM falou para parar, mas apavorou e correu porque estava com documentos irregulares. Estava só os dois (ele e o Paulo). Mora em Guará. O Golf é do pai, mas o pai não tem habilitação. Só ele dirige. Não tinha terceiro indivíduo no carro. Não conhece os policiais e não sabe por que eles mencionaram isso. O nome do pai estava sujo e transferiu o carro para Mateus. Vendeu e comprou o carro de volta. O carro estava no nome do Ramon antes. Teve que tirar do nome. O Paulo é vizinho e mora na Avenida Antônio Ribeiro dos Santos. Não tinha droga no carro. Desconhece essa droga. Não jogaram droga. A polícia abordou no momento em que estavam na propriedade rural do avô. Apresentaram na delegacia após uma hora e meia. Tinha o costume de ir a Franca (sistema informatizado - SAJ).

O acusado Paulo Roberto Honório, quando interrogado, disse que tem 56 anos. É pintor e pedreiro. Mora na Vila Vitória em Guará. É viúvo. Não respondeu outros processos criminais. Foi com o Roberto para visitar as filhas. Ia na Loja Pernambucanas também. Passaram por Ribeirão Corrente. Foram abordados e ele saiu correndo. Não tinha terceira pessoa e não estavam com drogas. Estava no banco da frente. Já foi usuário de drogas e está respondendo por furto de uma caixa d'água. É usuário de drogas - crack (sistema informatizado - SAJ).

Contudo, vê-se que a versão apresentada pelos réus não encontra respaldo no conjunto probatório presente nos autos, em especial pelos firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelas diligências.

A testemunha Renato José da Silva, Policial Militar, relatou que trabalha em Ribeirão Corrente. No dia dos fatos estava de serviço quando receberam informação de que o veículo Golf estava saindo de Ribeirão Corrente em atitude suspeita. Foram atrás e eles empreenderam maior velocidade. Solicitaram apoio de mais viaturas e próximo a Guará o passageiro da parte da frente jogou um objeto. Prosseguiram o acompanhamento. Eles entraram numa estrada de terra e tentaram se evadir. Localizaram dois indivíduos e o outro fugiu. Voltaram para ver o pacote e era mais de quatrocentos gramas de maconha. No momento da aproximação viu as fotos e reconheceu Ramon. Ele estava no momento que desembarcava do veículo. No 190 disseram que o veículo já tinha passado em Ribeirão outras vezes e era suspeito. Só

trabalhou em Guará em operações e não conhecia os réus. Recebeu ligação no dia do fato que esse veículo já tinha passado na cidade algumas vezes. Visualizaram os três na perseguição policial. Ramon estava dirigindo. A droga foi apreendida após a prisão dos dois. Estava perto de uma placa. O passageiro do banco da frente que jogou. Salvo engano foi o Roberto (sistema informatizado - SAJ).

No mesmo sentido, a testemunha Leonardo Enrique Pugina, Policial Militar, informou que trabalha em Ribeirão Corrente há mais de um ano. Era o motorista da viatura policial. Receberam delação anônima que um veículo Golf estava entrando em Ribeirão Corrente com frequência. Disseram que o carro estava com cheiro de entorpecente. Foram atrás e eles aumentaram a velocidade. O passageiro arremessou um objeto pelo vidro. Depois eles pararam o carro. O motorista conseguiu fugir. Solicitaram apoio para a PM de Guará. Voltaram e pegaram o objeto, que era droga. Enquanto a viatura de Guará ficou com os dois presos, voltaram para pegar o pacote que havia sido jogado. Não os conhecia. Em Ribeirão Corrente as delações caem direto na viatura. Não sabe quantos veículos passam no local por dia. Acredita que Golf branco seja raro passar no local. Não sabe se a pessoa que denunciou teve contato com o carro. A droga foi apreendida após a abordagem. Eles acessaram uma estrada de terra. Os dois foram abordados e o outro fugiu. Não se recorda da terceira pessoa. Sabe que era um homem. Um dos acusados disse que quem estava dirigindo era o irmão. Na delegacia ele disse que era o irmão. Não sabe se constou no boletim de ocorrência. A droga estava em torno de oito quilômetros do local da prisão (sistema informatizado - SAJ).

É de se consignar, neste momento, que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que goza da presunção de veracidade de seus atos. Primeiro porque suas declarações nas fases extrajudicial e judicial foram seguras e coerentes. Segundo, porque não se extrai dos autos qualquer indício de que seu objetivo seria o de incriminar injustamente o réu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Nesse sentido:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória" (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a validade do depoimento de policiais como prova, quando convergente com os demais elementos existentes nos autos:

"PROCESSUAL PENAL - PENAL - TESTEMUNHA POLICIAL - PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de 'habeas corpus', o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido". (STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade ao acusado, a par de seus relatos estarem acobertados pela fé pública.

A testemunha Carlos Alberto da Silva declarou que trabalha de eletricista. Ramon trabalhou com ele. Conhece o pai de Roberto. Nessa semana que eles foram presos, o Ramon estava trabalhando com ele. Não lembra o mês que aconteceu isso. Ramon trabalhou das 7h às 17h (sistema informatizado - SAJ).

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Nesse contexto, as delações anônimas, a apreensão da droga, a grande quantidade encontrada, a forma de seu acondicionamento, são fatores que não condizem com a versão apresentada pelos réus. Ao contrário, corroboram a versão dos policiais e a tese da acusação. Além disso, os policiais avistaram o momento em que a droga foi dispensada pelos acusados. Portanto, indubitável que os réus transportavam, para fins de tráfico, grande quantidade de substância entorpecente.

Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta "transportar" ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) o tráfico de droga dispensa a prática de ato de comércio à sua configuração, pois é crime de perigo abstrato, o qual se consuma com a simples guarda e depósito de substância entorpecente, afetando a saúde pública, que constitui o bem jurídico tutelado" (TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013).

"CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - agente que não é preso em flagrante vendendo a droga - Quantidade apreendida - Circunstâncias objetivas do crime - Configuração do ilícito. Para configuração do delito de tráfico, e irrelevante a quantidade maior ou menor da droga apreendida, nem é necessário que o agente seja surpreendido a vende-la, porque outras provas, circunstâncias objetivas, podem convencer o julgador acerca da existência do crime e sua autoria, como autoriza o artigo 37 da Lei Antitóxicos" (TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Prova - Palavra das rés que admitiram trazer consigo a droga - Depoimento de policiais - Validade - A reação apresentada pelas rés quando flagradas é incompatível com o alegado desconhecimento do conteúdo dos pacotes - A quantidade e o modo de acondicionamento revelam o intuito de comércio - Pena - Substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direito - Inadmissibilidade - Recursos não providos" (TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99).

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização" (RT 714/357).

Quanto ao veículo apreendido (VW/Golf, placas FIZ4800), utilizado para o transporte de drogas, deverá ser revertido ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, posto que utilizado para o transporte das drogas. Além disso, o réu Roberto afirmou que só ele dirigia o veículo e estava em nome do pai, que nem tem habilitação para dirigir.

Saliento que não prospera a tese defensiva, já que não há que se falar em

fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar aos réus a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos que tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Em conclusão, pelas condições reveladas acima, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputada aos réus, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS:

Por outro lado, não há prova do vínculo concreto que indique a associação entre os réus. Tais dados se restringem aos informes anônimos que ensejaram a diligência policial que resultou na apreensão da droga, bem como não havia delações anteriores sobre a participação dos réus no tráfico de drogas. E tais indícios, embora suficientes para a formalização do indiciamento, não se mostram bastantes a embasar decreto condenatório, já que não confirmados pelo conjunto probatório produzido em sede judicial.

Assim, e em consequência, o crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 não ficou caracterizado, já que não demonstrada a conjugação de condutas a apontar a associação, reiterada ou não, para o tráfico de drogas. No ponto, vale consignar a lição do professor Luiz Flávio Gomes, para quem "a associação para o tráfico exige apenas duas pessoas, ajustadas de forma estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, ou 34 desta Lei" (Nova Lei de Drogas Comentada, ed. RT, 2006, pg. 170). Nesse sentido, ainda, a jurisprudência dominante:

"O crime de associação não ficou caracterizado. Com efeito, de acordo com a lição de Guilherme de Souza Nucci, impõe-se a prova de estabilidade e permanência da associação criminosa. Segundo o autor, o elemento subjetivo do crime é o dolo. "Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico." (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição revista, atualizada e ampliada, 2007, p. 334). Assim, o fato de estarem duas ou mais pessoas comercializando entorpecentes, por si só, não caracteriza o delito de associação para o tráfico". (TJSP - 11ª Câmara Criminal, APELAÇÃO Nº 0032780-91.2010.8.26.0050 (990.10.573758-7), DJ. 1.06.2011, Rel. Xavier de Souza).

"TÓXICOS - Tráfico - Associação criminosa - Não configuração - Inexistência de elementos que demonstrem o vínculo associativo entre os três acusados - A prova aponta no sentido de que os réus estavam juntos para a prática do crime, mas não permite afirmar que havia, entre eles, vínculo permanente, duradouro, de modo a permitir tal condenação - Impossibilidade de caracterização do delito autônomo - Hipótese, que comporta a absolvição dos recorrentes pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 - Recurso parcialmente provido neste aspecto". (Apelação Criminal n. 993.08.040835-1 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, DJ. 31.07.08 V.U. - Voto n. 10.992).

"Entretanto, a associação não está provada. Exige-se prova de vínculo estável entre agentes com a finalidade da prática de uma série indeterminada de crimes. Este delito se consuma independentemente da prática de qualquer realização concreta de tráfico ou financiamento ao tráfico de entorpecente, evidenciando o caráter autônomo e formal do delito associativo, na forma do entendimento jurisprudencial já consolidado no STJ e no STF. (...) Nesse contexto, o delito autônomo do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, não está provado à ausência a prova segura da associação. VICENTE GRECCO FILHO, analisando o tema, explanou: "não será toda vez que ocorrer

concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um 'animus' associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria coautoria." (Lei de Drogas Anotada, Ed. Saraiva, 2007, p.120)" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0507864-86.2010.8.26.0000, DJ. 28.06.2011, Rel. Euvaldo Chaib).

Assim, não comprovada a estabilidade na associação, a absolvição, no ponto, se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

I) Em relação ao acusado ROBERTO CARLOS AMARO DIAS JÚNIOR:

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê como pena a privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (fl. 67 – proc. 0000459-86.2016.8.26.0213), razão pela qual fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Pela agravante da reincidência (fl. 67 – proc. 0000262-34.2016.8.26.0213) e com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, o que resulta em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Ausente circunstância atenuante.

Descabida a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, eis que o réu não atende a seus requisitos, pois é reincidente.

Assim, torno a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em obediência ao critério estipulado no artigo 33, §2º, b e §3º, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu, a indicar a conveniência do regime mais gravoso para a devida ressocialização.

Outrossim, tanto pelos fundamentos lançados, como também pela vedação expressa do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis, visto que insuficiente à repressão e prevenção do crime (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

No mais, considerando que o réu respondeu ao processo preso, concluo que persistem as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão cautelar, já que interessante à ordem pública e ao próprio prestígio do Poder Judiciário, pelo restabelecimento do sentimento de punição aos autores de delitos. E mais, se respondeu preso ao processo, seria no mínimo contraditório agora, em juízo de cognição exauriente (o que caracteriza o fumus boni iuris), sua condenação e soltura. Some-se sua reincidência, a caracterizar também o periculum libertatis. Assim, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

II) Em relação ao acusado PAULO ROBERTO HONÓRIO:

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê como pena a privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (fls. 78/81), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ausente causa de aumento de pena. Incide, por outro lado, a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu não ostenta antecedentes criminais e nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que reduzo a pena em 2/3, chegando ao total final de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, que torno definitiva à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, considerando que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que indica baixa capacidade econômica (fls. 508/510).

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, "c", e §3º, do Código Penal.

Diante da quantidade de pena aplicada e da presença dos demais requisitos subjetivos e objetivos, cabível a substituição de pena prevista nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos: a primeira consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual lapso temporal, em entidade a ser indicada por ocasião da execução; a segunda em prestação pecuniária de um salário mínimo, em favor de entidade também a ser definida pelo juízo da execução.

Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

- absolver ROBERTO CARLOS AMARO DIAS JÚNIOR e PAULO ROBERTO HONÓRIO, qualificados nos autos, da imputação da prática do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

- condenar ROBERTO CARLOS AMARO DIAS JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, negado eventual apelo em liberdade.

- condenar PAULO ROBERTO HONÓRIO, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, autorizado eventual apelo em liberdade. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos: a primeira consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual lapso temporal, em entidade a ser indicada por ocasião da execução; a segunda em prestação pecuniária de um salário mínimo, em favor de entidade também a ser definida pelo juízo da

execução.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, declaro perdido em favor da União o veículo (VW/Golf 1.6 SPORTLINE, ano/modelo 2012/2013, cor branco, placas FIZ4800-Guará/SP) apreendido em poder do réu, que será revertido diretamente ao FUNAD.

Os réus arcarão com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça, que ora lhe concedo, ante sua evidente hipossuficiência econômica.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos dos acusados, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Recomende-se o condenado ROBERTO CARLOS AMARO DIAS JÚNIOR no estabelecimento prisional em que se encontrar.

P.R.I.C.

Guara, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA